

1501747-58.2021.8.26.0297

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... está sendo acusada por ajudar Gustavo no tráfico.

Oleno Carlos Faria Garzella, investigador de polícia, conheceu Gustavo e Waissa dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de "crack". Disse que os réus são os responsáveis por buscar o entorpecente no Mato Grosso do Sul para abastecer as "biqueiras" de Jales-SP. Em uma das informações recebidas, soube que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501747-58.2021.8.26.0297 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501747-58.2021.8.26.0297

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2288530/2021 - 1º Distrito

Policial de Jales, 3753/2021 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA (filho de Sandra Ferreira da Silva, nascido em 01/08/1994, natural de Jales - SP, RG 49756069) e WAISSA FERREIRA GOMES DA SILVA (filha de Edilson Gomes e Clarice Ferreira Cruz, nascida em 15/12/1998, natural de Jales - SP, RG 55961983) foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, e nos termos dos artigos 29, 61, II, "j" (pandemia pela COVID-19), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 22h40min, na marginal Ayrton Senna, nº 1248, Centro, nesta cidade e Comarca de Jales-SP, agindo em concurso de agentes, nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de

qualquer natureza, de unidades policiais, traziam consigo e transportavam, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) tijolo de "cocaína", sob a forma de "crack", acondicionado em embalagem plástica, com peso líquido aproximado de 996,15 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. Notificados (p. 232 e 234), os réus defenderam-se previamente por intermédio de sua advogada constituída (p. 276/281).

Recebeu-se a denúncia em 16 de dezembro de 2021 (p. 299/303).

Os réus foram citados pessoalmente (p. 340 e 344).

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) - foram ouvidas duas testemunhas de acusação (Oleno Carlos Faria Garzella e Igor Alexandre Murari Cardozo) e das testemunhas de defesa (Ricardo Signorelli e João Victor de Souza Vieira). Por fim, interrogou-se os réus.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência em parte do pedido. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, para ambos, tendo-se em vista a quantidade e a natureza do entorpecente. Ainda, suscitou a existência da agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP. Pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao réu Gustavo. Rechaçou a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da LD, bem como da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da LD. Pugnou pela fixação do regime inicial fechado aos réus. Por fim, opinou pelo perdimento da quantia (R\$155,00) e do veículo apreendidos (p. 440/463).

Sobreveio pedido de restituição do veículo apreendido por parte da terceira interessada CLARISSE FERREIRA DA SILVA (p. 468/477), sobre o qual o Ministério Público manifestou contrariedade (p. 515/516).

A defesa de Waissa requereu a absolvição da ré por insuficiência probatória.

Subsidiariamente pediu a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da LD, em patamar máximo (2/3).

Suscitou ser inaplicável a agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP e da causa de aumento de pena do art. 40, III, do LD. Ainda, pugnou pela aplicação do regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mais, postulou a concessão do direito de a ré recorrer em liberdade, além da restituição do veículo apreendido (p. 517/552).

Por sua vez, a defesa de Gustavo requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente pediu a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da LD, em patamar máximo (2/3). Suscitou ser inaplicável a agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP e da causa de aumento de pena do art. 40, III, do LD. Ainda, pugnou pela aplicação do regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mais, postulou a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade, além da restituição do veículo apreendido (p. 517/552).

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), imputado aos réus Gustavo e Waissa, está provada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/02), pelo boletim de ocorrência (p. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (p. 17/18), pelo laudo de constatação prévia (p. 19/21), pelo laudo de exame definitivo de entorpecente (p. 185/187) - que atestou que a droga apreendida tratava-se de "cocaína" -, pelo laudo de veículo apreendido (p. 289/289), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

O réu Gustavo, interrogado em juízo, admitiu a prática do tráfico de entorpecentes. Como seu relacionamento estava em crise, resolveu passear com a família em Santa Fé do Sul-SP. Antes de retornar, passaram em Ilha Solteira-SP para pagar dívida de um carro, com um "tal de Fernando". Não comprou o carro dele. Comprou o "New Fiesta", prata, no ano de 2019. Pagou vinte e sete mil reais pelo veículo. Ficou devendo quinhentos reais. Precisou vender o veículo para dar entrada no estabelecimento do

casal. Venderam o carro para "Fernando". O vendedor recebia as parcelas em sua casa. Depois voltaram para Jales-SP e, ao passar pelo "Proença", percebeu que estava sendo acompanhado pela polícia. Waissa e seu filho dormiam no carro. Arremessou a droga pela janela. O entorpecente estava dentro do veículo desde tarde. O veículo "Ônix" pertence à avó. Colocou o entorpecente no interior do carro e esqueceu-a. Admitiu ter desobedecido as medidas cautelares diversas da prisão. Entregaria a droga no final da tarde. Morava com Waissa naquela época. Foi até uma praça na avenida principal de Santa Fé do Sul-SP. A droga não lhe pertencia, só entregaria a um traficante. Não sabia o quanto valia o entorpecente, mas receberia dois mil reais pelo transporte. Parou o veículo quando ouviu um tiro. Não correu dos policiais. Um dos policiais mandou o outro dar mais tiros nos pneus do carro depois que havia parado. Não informou tal fato quando interrogado em delegacia, porque estava "sem chão". Não falou nada para Waissa. A ré acordou quando passou por uma lombada. Contou para a convivente que a polícia estava perseguindo-os, porque havia droga no veículo. Foi a primeira vez que transportou entorpecente. Arremessou a droga perto da concessionária "Viviane Motores". Nenhuma viatura ficou emparelhada ao seu veículo. Waissa está sendo incriminada, porque o acompanhava no veículo. Precisava de dinheiro, por isso aceitou transportar o entorpecente. Não buscou o entorpecente em Aparecida do Taboado-MS. Arrepende-se do que fez.

A ré Waissa, interrogado em juízo, negou o tráfico. Gustavo convidou-a para sair com o filho do casal. Foram passear em Santa Fé do Sul-SP e, na volta, passaram em Ilha Solteira-SP para pagar a prestação do carro. Ficaram na praça central de Santa Fé do Sul-SP por duas horas. Tinham um "Corsa". Faltava uma parcela de quinhentos reais para quitar o veículo. Não soube dizer o nome da pessoa de quem comprou o veículo. Gustavo vendeu o "Corsa" assim que abriram o estabelecimento. Dormiu na volta para Jales-SP, tendo acordado quando Gustavo passou por um quebra-molas. Viu as luzes das viaturas e pediu para Gustavo parar o veículo. Gustavo pegou algo debaixo das pernas e lançou pela sua janela. Não sabia do que se tratava o objeto lançado. Indagada sobre ter dito em delegacia que "não viu o réu jogar nada pela janela", explicou ter relatado esse fato ao delegado. Havia película nos vidros do carro. Não tinha ciência da droga existente no carro e nem a arremessou pela janela. Não observou se a viatura ficou emparelhada ao veículo. Batalha muito em sua vida, inclusive, dá "seu sangue" no "Açaí". Não precisava traficar para viver. Gustavo pediu desculpas por tê-la envolvido nessa situação. Conhecia "Jidi", porque ele trabalhava para o pai da interrogada como entregador. Conseguia retirar um salário de mil e duzentos reais do "Açaí". Não sabe o porquê está sendo acusada por ajudar Gustavo no tráfico.

Oleno Carlos Faria Garzella, investigador de polícia, conheceu Gustavo e Waissa dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de "crack". Disse que os réus são os responsáveis por buscar o entorpecente no Mato Grosso do Sul para abastecer as "biqueiras" de Jales-SP. Em uma das informações recebidas, soube que Gustavo levaria quantidade grande de droga para abastecer "Jidi", um traficante conhecido da cidade. Conseguiram prender Gustavo em flagrante na residência de "Jidi". De acordo com o delegado de polícia, naquela ocasião, apreenderam uma balança com resquícios de "crack" com o réu. Continuaram a receber informações da continuidade do tráfico depois que Gustavo foi posto em liberdade. Soube que a droga de Gustavo estava acabando e, por isso, ele viajaria para buscar mais entorpecente. Gustavo levava a esposa e o filho em suas viagens para, se caso abordado, despistar os policiais. No dia dos fatos, receberam informações de que Gustavo rumava até a cidade de Três Lagoas-MS para buscar drogas. Aguardaram o réu em um posto de gasolina na cidade de Urânia e viram-no passar pela rodovia. Acompanharam o veículo, tendo ligado o "giroflex" e a sirene da viatura assim que Gustavo entrou no trevo de Jales-SP, que dá acesso ao bairro Arapuã. Gustavo empreendeu fuga em alta velocidade, sendo necessário realizar disparos de arma de fogo nos pneus do veículo. Em frente à concessionária "Toyota" viu Waissa arremessando o tijolo de entorpecente pela janela. Emparelhou a viatura ao carro de Gustavo, conseguindo furar o pneu com um disparo. Conseguiram abordá-los em frente a um posto de gasolina. Outra viatura voltou para buscar o tijolo de droga arremessado por Waissa. Dada voz de prisão aos réus, conduziram-nos à delegacia. O filho do casal,

de cinco anos de idade, estava no interior do veículo. Gustavo vendia drogas para outros traficantes. Sabe que os réus trabalhavam no "Açaí". Durante um ano receberam informações do envolvimento dos réus no tráfico. Não havia compartimentos no carro. Waissa ocupava o banco da frente do passageiro. Conseguiu vê-la arremessando o tijolo, porque a viatura ficou ao lado do veículo. A ré tinha função de auxiliar a pesagem e venda da droga no "Açaí", além de acompanhar o esposo nas viagens. Gustavo vendia grandes quantidades de entorpecente.

Igor Alexandre Murari Cardozo, investigador de polícia, disse que receberam informações que Gustavo e Waissa eram responsáveis pelo abastecimento de "crack" na cidade de Jales-SP. Inclusive alguns diziam que eles eram "os mais fortes no crack". Alguns meses antes da ocorrência, Gustavo foi preso em flagrante ao entregar drogas a outro traficante. No dia dos fatos, souberam que Gustavo buscava entorpecentes em Três Alagoas-MS. Aguardaram-no na cidade de Urânia-SP e, assim que passou pela rodovia, acompanharam o réu até a cidade de Jales-SP. Ligaram os sinais luminosos e sonoros da viatura para tentar abordar o veículo, mas o réu empreendeu fuga, por aproximadamente dois quilômetros, na marginal. Conseguiram imobilizar o veículo com disparos de arma de fogo. Waissa dispensou um objeto pela janela antes do veículo parar. Constataram que o objeto tratava-se de um tijolo de "crack". Uma viatura emparelhou com o veículo dos réus e outra viatura ficou atrás. Estava na viatura de trás. Sabe que Gustavo tem um estabelecimento de açaí. Não identificaram compartimentos para armazenar drogas no veículo.

Por sua vez, as testemunhas Ricardo Signorelli e João Victor de Souza Vieira em nada puderam contribuir ao desenrolar do processo, pois não presenciaram os fatos. Como se nota, a confissão do réu Gustavo encontra amparo no contexto probatório. Observa-se que o tijolo de entorpecente transportado por ele destinava-se ao tráfico, mormente pela grande quantidade (quase um quilo) de droga que trazia consigo. Ademais, o próprio réu admitiu que o entorpecente foi encomendado por um traficante da cidade de Jales-SP, bem como, que ganharia dois mil reais pelo transporte.

Pelos relatos dos policiais Oleno e Igor, o réu seria o responsável pelo abastecimento de "crack" nas "biqueiras" de Jales-SP. Para tanto, buscava o entorpecente no Estado do Mato Grosso do Sul, sempre viajando em companhia da esposa, no intuito de evitar maiores suspeitas em casa de abordagem policial. Disseram que Gustavo inclusive foi preso em flagrante quando realizava entrega de drogas para "Jidi", traficante conhecido nos meios policiais. Tais declarações foram corroboradas pelos boletins "disque denúncia" de p. 37/40, nos quais há notícia do envolvimento do réu no tráfico de drogas.

Por outro lado, a versão de Waissa é inverossímil. Embora negue o envolvimento com o tráfico de droga, constata-se, na realidade, que a ré praticou referido crime no núcleo verbal "transportar". Isso porque seria impossível ignorar a existência da grande quantidade de entorpecente - tanto pelo volume ocupado por um tijolo de drogas quanto pelo cheiro exalado no ambiente - transportada no interior do veículo pelo esposo Gustavo.

Além do mais, as testemunhas Oleno e Igor, viram o momento em que Waissa dispensou o entorpecente pela janela durante a perseguição policial - comportamento que denota a ciência da ré sobre a ilicitude do pacote dispensado. De acordo com os policiais, haviam informações na DISE sobre o envolvimento de Waissa, junto com Gustavo, na prática do tráfico de entorpecente, que foi corroborado pelo documento de p. 38.

Ao contrário do suscitado pelos réus em autodefesa, inexistente qualquer elemento de prova a indicar que os policiais - os investigadores no momento da abordagem e o delegado de polícia quando do interrogatório em fase de inquérito - quisessem prejudicar a casal indevidamente.

Assim, diante do conjunto probatório, não há dúvidas de que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, os réus Gustavo e Waissa, traziam consigo e transportavam, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) tijolo de "cocaína", sob a forma de "crack", acondicionado em embalagem plástica, com peso líquido aproximado de 996,15 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. Fato que se amolda ao tipo penal previsto no art.

33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

Por fim, não há de se falar em incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o laudo pericial de p 289/298 não constatou a presença dos estabelecimentos listados no mencionado dispositivo legal.

Configurada a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos réus, passa-se a fixação da pena.

Quanto ao réu GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, na primeira fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias judiciais em seu desfavor. Por outro lado, deve ser sopesada a grande quantidade (quase um quilo) de droga apreendida, denotando maior censurabilidade ao comportamento do réu. Desse modo, inauguro a pena base acima do mínimo legal, fixando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem analisadas. Frise-se que a circunstância agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, deve ser afastada, porque não ficou demonstrado que o réu se prevaleceu da pandemia para praticar o crime. Contudo, reconheço a circunstância atenuante oriunda da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). O réu admitiu ter transportado o entorpecente, pelo valor de dois mil reais, com detalhes, conforme exige o Enunciado nº 630 da Súmula do STJ. No entanto, considerando que a redução da pena em fração de 1/6 conduziria a pena aquém do mínimo legal (STJ, 231), reduzo a pena intermediária ao piso da lei, ou seja, pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem analisadas. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque, o réu é primário e não há provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Registre-se que este juízo vinha levando em consideração a reiteração na prática do tráfico de entorpecentes - ainda que em processamento - para afastar o privilégio legal. Contudo, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento da Quinta e Sexta Turmas - para alinhá-las às decisões do Supremo Tribunal Federal -, no sentido de que "(...) a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal" (HC 664.284/ES, Quinta Turma do STJ, rel. Ministro Riberio Dantas, ocorrido em 21/9/2021, DJe 27/09/2021). Desse modo, diminuo a pena aplicada ao tráfico em 2/3, fixando a pena definitiva em pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, porque a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e o réu é primário. Consigne-se que a equiparação à hediondez do tráfico privilegiado foi afastada por decisões do Superior Tribunal Federal (HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016) e do Superior Tribunal de Justiça (Tese Firmada no Tema 600 dos Recursos Repetitivos, publicada em 29/11/2016). Portanto, não deve incidir a determinação do § 1º do artigo de 2º da Lei nº 8.072/90.

Deixo de computar o período de prisão provisória para fins de detração determinado pelo §2º do art. 387 do CPP, ante a fixação o regime inicial de cumprimento de pena

mais brando.

Substituto a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), o réu não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º): prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Com relação à ré WAISSA FERREIRA GOMES DA SILVA, na primeira fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias judiciais em seu desfavor. Por outro lado, deve ser sopesada a grande quantidade (quase um quilo) de droga apreendida, denotando maior censurabilidade ao comportamento da ré. Desse modo, inauguro a pena base acima do mínimo legal, fixando a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica da ré (LD, 43, caput).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem analisadas. Frise-se que a circunstância agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, deve ser afastada, porque não ficou demonstrado que a ré se prevaleceu da pandemia para praticar o crime. Assim, mantém-se a pena intermediária no patamar anterior.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena a serem analisadas. Por outro lado, reconheço a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, porque, a ré é primária e não há provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Desse modo, diminuo a pena aplicada ao tráfico em 2/3, fixando a pena definitiva em pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica da ré (LD, 43, caput).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, porque a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e a ré é primária. Consigne-se que a equiparação à hediondez do tráfico privilegiado foi afastada por decisões do Superior Tribunal Federal (HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016) e do Superior Tribunal de Justiça (Tese Firmada no Tema 600 dos Recursos Repetitivos, publicada em 29/11/2016). Portanto, não deve incidir a determinação do § 1º do artigo de 2º da Lei nº 8.072/90.

Substituto a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, por meio da Resolução nº 5/12, o Senado Federal suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, e, sobretudo, porque a pena privativa de liberdade não é superior a 4 (quatro) anos (CP, 44, I, primeira parte), o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, 44, I, segunda parte), o réu não é reincidente em crime doloso (CP, 44, II) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja

suficiente (CP, 44, III).

Como a pena privativa de liberdade supera 1 (um) ano, faz-se a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, 44, § 2º): prestação pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido e condeno GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA (filho de Sandra Ferreira da Silva, nascido em 01/08/1994, natural de Jales - SP, RG 49756069) e WAISSA FERREIRA GOMES DA SILVA (filha de Edilson Gomes e Clarice Ferreira Cruz, nascida em 15/12/1998, natural de Jales - SP, RG 55961983), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) salários-mínimos em dinheiro à entidade pública ou privada com destinação social; e prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, ambas a serem especificadas no momento da execução.

Condeno os réus Gustavo e Waissa no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça.

Poderão os condenados recorrerem em liberdade, pois o tipo de pena aplicada incompatibiliza-se com a prisão preventiva. Revogo a prisão preventiva de GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulados ao réu GUSTAVO. Revogo a medida cautelar de recolhimento domiciliar de WAISSA FERREIRA GOMES DA SILVA.

Quanto à quantia (R\$155,00) - constante do auto de apreensão e exibição de p. 17/18 -, considerando que os condenados não comprovaram a origem lícita do valor, bem como por guardar correlação com crime de tráfico de drogas, decreto-lhe o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

No tocante ao veículo ("CHEVROLET/ONIX 1.4MT LT"), constante do auto de exibição e apreensão de p. 17/18, porque utilizado como instrumento à prática de tráfico de entorpecentes pelos condenados - conforme declarado pelas testemunhas Oleno e Igor -, decreto-lhe o perdimento em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06).

Consequentemente, indefiro o pedido de restituição do veículo formulado por Clarisse Ferreira da Silva (p. 468/477). Gustavo, interrogado em juízo, afirmou que fazia uso do bem, pois a avó não dirigia. Waissa admitiu, também, utilização do veículo, em razão das necessidades do filho do casal. Denota-se, portanto, que os réus mantêm a posse sobre o veículo. Por outro lado, a terceira interessada deixou de acostar aos autos documentos que comprovassem a aquisição do veículo - tais que contrato de compra e venda ou comprovante de pagamento. Limitando-se a apresentar documentos médicos (p. 478/509) sem vínculo como o objeto de sua pretensão. Vale lembrar que o simples fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro não implica presunção de que não seja de propriedade de Gustavo, haja vista que os bens móveis transferem-se por simples tradição.

Registre-se que a destinação dos celulares apreendidos já foi analisada em decisão de p. 223/224.

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Consigne-se que a destruição das drogas apreendidas já foi determinada pela decisão de p. 120/126. Após o trânsito em julgado, deverão ser destruídas as amostras guardadas para contraprova, certificando isso nos autos (art. 72 da Lei nº 11.343/06 com a redação dada pela Lei nº 12.961/14).

Com o trânsito em julgado: expeçam-se guias de recolhimento para execução das penas (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intimem-se os condenados para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional

Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral dos apenados para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); remeta-se ao SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) a relação da quantia e bem declarado perdido em favor da União, indicando o local em que se encontram e o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente (art. 63, § 4º da Lei nº 11.343/06); e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA